



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

אמיתי אסולין דינה, ת.ז.

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד מרדכי חזיזה
בית הדפוס 11, ירושלים

נגד

כהן לאה שושנה, ת.ז.

3

נתבעים

קהאן אוטו

4

באמצעות ב"כ: עו"ד אריאל ינובסקי
כנפי נשרים 68, ירושלים

כהן לאה שושנה, ת.ז.

1

בתיק:
1/179/2021

תובעים שכנגד

קהאן אוטו

2

באמצעות ב"כ: עו"ד אריאל ינובסקי
כנפי נשרים 68, ירושלים

נגד

אמיתי אסולין דינה, ת.ז.

נתבעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד מרדכי חזיזה
בית הדפוס 11, ירושלים

פסק דין (תביעה שכנגד)

עניינו של פסק דין זה הוא פרשנות סעיף בתקנון המוסכם של בית המשותף, בנוגע לשיוך זכויות בנייה ואחוזי בניה, שנוספו לאחריו, לאחת הדירות.

1. הצדדים להליך הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף ברחוב אבן עזרא 26 בירושלים, הרשום כגוש 30025 חלקה 6 (להלן – הבית המשותף). לבית המשותף תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום ביום 9.8.1988. הבית המשותף כולל שני מבנים, באחד 5 יחידות דיור (תתי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- חלקות 1-5), והשני כולל יחידה אחת (תת חלקה 6) המופיעה בצו רישום הבית המשותף כמחסן. התקנון המוסכם קובע שגג בשטח של 216.2 מ"ר ומרפסת בשטח 10.8 מ"ר יוצמדו לדירה 5, וגינה בשטח של 358.2 מ"ר וכן גג בשטח של 7.9 מ"ר יוצמדו ליחידה 6. מעבר לכך לא נקבעו הצמדות מסוימות לדירות נוספות. כן קובע התקנון כי "זכויות הבניה ואחוזי הבניה יהיו רק לדירה מס' 5".
2. בשנת 2015 נכנסה לתוקף תכנית 9988, החלה בין היתר על הבית המשותף, אשר אישרה תוספת משמעותית של זכויות בניה לבניינים שבתחומה, ובכללם לבית המשותף.
3. ההליך החל בהגשת תביעה על ידי הנתבעת שכנגד (להלן – הנתבעת) לסילוק ידם של התובעים שכנגד (להלן – התובעים) מרכוש משותף של הבית המשותף, בו הם משתמשים במסגרת הרחבת דירתם. הרחבת הדירה נעשתה לטענת הנתבעת ללא ההסכמות הנדרשות מבחינה קניינית, ותוך שימוש בזכויות הבניה אשר על פי התקנון המוסכם של הבית המשותף שייכות לדירת הנתבעת.
4. התובעים מצדם הגישו תביעה שכנגד, במסגרתה ביקשו לאסור על הנתבעת לבנות ולהשתמש באחוזי בניה מעבר לזכויותיה הנטענות על ידם.
5. בדיון מקדמי שהתקיים ביום 25.1.2022 הגיעו הצדדים להסדר דיוני כדלקמן:

"ב"כ הצדדים: מוסכם כי במסגרת הדיווח של הנתבעים (התובעים דכאן, א.ש) לרשויות המס לא דווח כי קיימות זכויות בניה לדירה, כמו כן מוסכם כי ככל שתינתן תשובה בכתב מטעם מוכרי דירת הנתבעים לעניין היטל ההשבחה, לא יהיה צורך בהבאת ראיות נוספות או בעדויות, והתיק ייקבע לסיכומים בכתב על בסיס עובדות אלו בלבד, וטענות משפטיות לעניין פרשנות התקנון. ככל שתחול הסכמה דיונית כאמור, התובעים (הנתבעת דכאן, א.ש) ימחקו את התביעה העיקרית, פסק הדין יינתן בתביעה שכנגד, ובהתאם לתוצאות פסק הדין, יהיו התובעים רשאים לחזור ולהגיש תביעה."
6. בעקבות הסכמות אלו, נמחקה התביעה העיקרית (בתיק 106/2021) ביום 13.3.2022, והצדדים הגישו סיכומים בכתב בנוגע לתביעה שכנגד.
7. עיקרה של המחלוקת נוגעת לפרשנות סעיף 3(א) לתקנון המוסכם הקובע כאמור לעיל ש"זכויות הבניה ואחוזי הבניה יהיו רק לדירה מס' 5".
8. התביעה שכנגד הוגשה כנגד הנתבעת בלבד, כבעלת הזכויות בדירה מספר 5, אף שעל פי נסח הרישום קיימים בעלי זכויות נוספים. גם הנתבעת מצדה רואה עצמה כבעלת הזכויות היחידה בדירה מספר 5 כפי שעלה מסעיף 7 לכתב התביעה העיקרי. כמו כן מההסכמות הצדדים עולה כי לא קיימת מחלוקת עובדתית בעניין זה. משכך, אני רואה בצדדים כמי שהסכימו שהנתבעת היא בעלת הדין הרלוונטית להליך, כבעלת הזכויות בדירה 5.

עיקר טענות התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. לטענת התובעים, יש לפרש את סעיף 3(א) לתקנון המוסכם כמתייחס לזכויות הבנייה ולאחוזי הבניה שהיו ידועים ביום אישור התקנון, ולא כמתייחס לזכויות עתידיות ולבנייה על הגג שיווצר כתוצאה מהבנייה על הגג הקיים.

10. לצורך הצמדת הגג החדש לדירת הנתבעת, יש צורך בקביעה מפורשת בתקנון או בהסכמת יתר בעלי הדירות, ואין די בקביעה משתמעת.

11. לטענתם, אין בהוצאת שומת היטל השבחה לנתבעת כדי ללמד על זכויותיה בבית המשותף, שכן קביעה בדבר זכויות כאמור אינה בסמכות הרשות המקומית.

12. לטענתם, זכויות הבניה העודפות על פי תכנית 9988 שייכות לכל בעלי הדירות, וחישוב זכויות בעלי הדירות צריך להיעשות בהתאם לשטח הנוסף שניתן כיום לבניה על גבי החלקה (על פי חוות דעת שצירפה הנתבעת לתביעה העיקרית), בחלוקה על פי חלקם היחסי של בעלי הזכויות בבית המשותף. בהתאם לכך, לנתבעת זכות לבנות על הגג הצמוד לה רק בהתאם לחלקה היחסי בזכויות הבניה העודפות על פי תכנית 9988, באופן המביא לכך שקיימת לה זכות לבנות רק 30.5 מ"ר על הגג הצמוד לה, ולא 286.67 מ"ר בשתי קומות, כטענתה.

13. לטענתם, העובדה שלא דיווחו לעיריית ירושלים או לרשויות המס על זכויות בניה אינה אמורה לפגוע בהם שכן סברו בטעות שאין להם זכויות בניה אך מעולם לא ויתרו עליהן.

עיקר טענות הנתבעת

14. לטענת הנתבעת לשון סעיף 3(א) לתקנון המוסכם היא לשון עתיד, וכן סעיף 3(ב) לתקנון המוסכם נתן לנתבעת חופש לשנות את התקנון כרצונה, ועל כן יש לפרש את התקנון כמקנה לדירתה גם זכויות בניה עתידיות, הכוללת את הזכויות על פי תכנית 9988.

15. לטענתה, התובעים, אשר רכשו את דירתם לאחר כניסת התכנית לתוקף, בדקו את מסמכי הרישום כאשר רכשו את דירתם, ידעו שאין להם זכויות בניה, וכך אף דיווחו והצהירו לרשויות המס ומוכרי דירתם אף הצהירו כאמור לעיריית ירושלים לעניין היטל השבחה. התובעים הצהירו בהסכם המכר שבדקו את המסמכים הרלוונטיים ואף ידוע להם שכנראה ניתן היתר לתוספת בנייה לבעל דירה 5.

16. לטענתה, הנכס נרכש על ידי בעלה המנוח של הנתבעת, לצורך הבטחת ילדיו, משום שידע על התכנית הצפויה להיכנס לתוקף. לטענתה גם האפוטרופוס הכללי מנע את מכירת הדירה על ידה בין היתר לנוכח העובדה שהוצמדו לנכס מלוא זכויות הבניה באופן הנותן ביטוי לדאגה הכלכלית ליתומים. עוד לטענתה, בעבר היה כל הבית המשותף רשום בחלקים שווים על שם שתי אחיות חסויות, ובמרוצת השנים נמכרו 3 דירות אחרות, תוך ש-3 תתי חלקות, ובכללן תת חלקה 5 לא נמכרו, במטרה להשאיר בידי הבעלים המקוריים את כל הזכויות המשויות לאותן תתי חלקות.

17. עוד לטענתה, בעת שנרשם התקנון ניתן היה להניח שבעתיד ישתנו זכויות הבניה. בנוסף, ניתן ללמוד על אומד דעת התובעים באשר לזכויות הבניה גם מהתנהלותם כפי שהיתה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנוגע לרכישת דירתם. לפיכך אי דיווח התובעים על זכויות הבניה לעירייה ולרשויות המס והתנהלות המוכרים במהלך השנים בכלל, מוכיחה שאין להם זכויות בניה.

דיון והכרעה

מעמדן של זכויות הבניה

18. בפסיקה נקבע שזכויות בניה בבית משותף הן נכס בבעלות משותפת, שיש להן ערך כלכלי, וכברירת מחדל יחולקו בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (ר' ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן (נבו, 18.2.2010) (להלן – עניין קאופמן); ע"א 11965/05 עזבון המנוח קליין נ' שרון (נבו, 27.8.2009); ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, נד (3) 389, בעמ' 393 (להלן – עניין גלמן); ע"א 467/14 שטינברג נ' חברת לילינבלום 13 (נבו 9.9.2015) בפסקה 19).

19. כן נקבע בפסיקה כי זכויות בניה "יכול שתהיינה מושא להסכמות חוזיות, לרבות: ויתור עליהן, או העברתן לאחר" (ע"א 2139/12 רוזן נ' חברת ארזי הבירה (נבו 15.12.15); עניין קאופמן לעיל).

בע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, נט(6) 449 נקבע בעניין זה:

"זאת ועוד, גם אין מניעה לכלול את ההסכמות בעניין זכויות הבניה בתקנון הבית המשותף, מאחר שמדובר בזכויותיהם וחובותיהם של בעלי הדירות 'בקשר לבית המשותף' (סעיף 61 לחוק המקרקעין). 'התקנון עשוי שיתייחס לשאלה מי מבין בעלי הדירות רשאי לנצל את אחוזי הבניה שנתרו לבית' (י' ויסמן, דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז), בעמ' 434. כן ראה ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד (2) 497, בעמ' 501-503). הכללת ההסכמות החוזיות בתקנון הבית המשותף תבטיח את תוקפן גם כלפי חליפיהם של בעלי הדירות (זמיר בספרו הנ"ל, בעמ' 691)".

20. מכאן שאין מניעה לקבוע הוראה בתקנון, כפי שנעשה בענייננו, המקנה את כל זכויות הבניה שבבית המשותף לבעל דירה מסוימת.

הקניית זכויות בניה עתידיות

21. בפסיקה נקבע ש"השאלה למי הוקנו זכויות הבניה, כאמור, היא שאלה שבעובדה, עליה יש להשיב בהתבסס על הראיות המוצגות בכל מקרה ומקרה, ובכללם הסכמי המכר, המפרטים שצורפו להם, ועל בית המשפט לבחון האם יש בראיות שהוצגו בפניו כדי לשכנע באשר לכוונת הצדדים לעניין העברת הזכויות בנכס, וזכויות הבניה העתידיות ככל שקיימות או ככל שתהיינה" (ע"א 2427/11 מפעל חסד תורה ירושלים ת"ו נ' ננסי פליישמן, (נבו 11.3.2014) (להלן – עניין מפעל חסד תורה); ה"פ 62782-09-17 (מחוזי ת"א) כהן ואח' נ' יורקום נדל"ן - ניהול פרויקטים (1990) בע"מ ואח' (נבו, 26.12.2019), וכן ע"א 6900/14 לויט נ' בנבנישתי (נבו 28.9.2016)).

22. מהפסיקה האמורה עולה שאין מניעה עקרונית לקבוע בתקנון הוראות לעניין הקניית זכויות בניה עתידיות, והשאלה האם הוקנו זכויות כאמור, היא שאלה עובדתית.

האם במקרה דנן, לדירה 5 הוקנו זכויות בניה עתידיות על פי התקנון?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. לשון סעיף 3(א) לתקנון היא לקונית, ואינה תומכת באופן חד משמעי בפרשנות הנטענת על ידי מי מהצדדים. במצב דברים זה, נטל ההוכחה על התובעים, להוכיח את טענתם שכוונת הצדדים היתה להקנות לדירה 5 את זכויות הבניה שהיו בעת רישום התקנון בלבד.

24. לאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים, אשר ויתרו על הגשת ראיות, הבסיס העובדתי לבחינת השאלה האם במקרה דנן הוקנו לדירה 5 זכויות בניה עתידיות הוא תקנון הבית המשותף ומסמכי הרישום, והעובדה שאינה שנויה במחלוקת, שבמסגרת הליך מכירת הדירה לתובעים, לא הוצהר לרשויות המס על קיומן של זכויות בניה לדירת התובעים, ומוכרי דירת התובעים לא שילמו היטל השבחה.

25. באשר לתקנון בית משותף נקבע בפסיקה ש"תקנון בית משותף הוא בגדר הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף. ככל הסכם יש לפרשו על-פי אומד-דעת הצדדים", וכי יש לתת לו " ... פירוש המגשים את תכליתם הכלכלית המשותפת של הצדדים, מתוך יחוס להם סבירות והוגנות ... " (ר' עניין גלמן לעיל). משנרשם התקנון בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לו מעמד קנייני (ר' רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ' שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)).

26. בנוסף נקבע, שויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית המשותף, בין שמדובר בזכות ברכוש משותף ובין שמדובר בהסכמה לבנייה (היינו, ויתור על אחוזי בנייה) חייב להיות מפורש (עניין גלמן לעיל בעמ' 394, וכן ע"א 310/64 אחים גולדשטיין בע"מ נ' יעקב פ"ד יט (2) 72, בעמ' 77).

27. בענייננו כאמור, הוראות התקנון קובעות כי גג בשטח 216.2 מ"ר יוצמד לדירה מספר 5, בנוסף קובעת הוראת סעיף 3 לתקנון:

3. בהתאם לאמור בסעיף 61-62 לחוק, אנו קובעים בזה:
א. זכויות בניה ואחוזי בניה, יהיו רק לדירה מס' 5.
ב. זכותם של בעלי הדירה מס' 5, לבקש תיקון צו לכא הסכמת יתר בעלי היחידות, ולאשר שינוי לתקנון.

28. מתקנון הבית המשותף עולה שכאשר נרשם, היו בכל הדירות בו זכויות בעלות בחלקים שווים לליון אביבה וגלותה, שתיהן חסויות.

29. סעיפים 61-62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) אליהם מפנה התקנון, עוסקים בתקנון בית משותף, ובכלל זאת ברוב הדרוש לשינוי תקנון.

30. אמנם תקנון הבית המשותף לא ציין במפורש שכוונתו גם לזכויות בניה עתידיות, אך לשון סעיף 3(א) שהיא לשון עתיד – "יהיו", וכן השימוש במילה "רק", וכן העובדה שהצמדת גג המבנה בו נמצאת דירה 5 נעשתה לדירה זו, מחזקים את המסקנה שהכוונה היתה לתת לבעלי דירה 5 לא רק זכויות בניה קיימות, אלא גם עתידיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כפי שנקבע בפסיקה בעניין דומה: "אין בידינו לקבל את הטענה שאת ההסכמה כפי שגולמה בתקנון יש לפרש כתלויה ביכולת ניצול אחוזי הבנייה בעת שנרשם התקנון. האפשרות שאחוזי הבנייה יוגדלו בעתיד אינה מפתיעה, ויש לראותה כצפויה במציאות החיים בארץ" (ע"א (מחוזי י-ם) 25959-05-10 שפירא לוי נ' שלומית יקיר (נבו 22.3.2011 פסקה 7), ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה ברע"א (2912/11). מכאן שסביר להניח שמנסחי התקנון לקחו בחשבון את האפשרות לתוספת זכויות בניה לאחר רישומו.

31. סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין, המוזכר בסעיף 3 לתקנון, קובע בין היתר שלא ניתן לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. במועד שבו נרשם התקנון, בשנת 1988, עדיין לא היה בתוקף תיקון מספר 18 לחוק המקרקעין, שנכנס לתוקף בשנת 1995, וקבע שעל אף הוראת סעיף 62(א) ניתן להרחיב דירה על חשבון הרכוש המשותף בהסכמה של הרוב הקבוע בסעיף, דהיינו, גם ללא הסכמת חלק מבעלי הדירות.

ניתן להניח שעל פי המצב המשפטי שהיה קיים בעת שנרשם התקנון, סברו מנסחי התקנון שאין היתכנות כלל לתוספת בניה שתבוצע על ידי בעלי הדירות האחרות, שכן לא בוצעו הצמדות לדירות אלו, וללא הסכמת בעלי דירה 5, בהתאם לאותו מצב משפטי, גם לא ניתן היה לבצע תוספות כאמור, אף במצב שבו תכנית עתידית היתה מאפשרת זאת.

לפיכך הפרשנות שהכוונה בתקנון היתה לתת לדירה 5 את כל זכויות הבניה במובן הרחב, שכן ממילא היא היחידה שיכלה לנצל זכויות בניה כאמור ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, בשל העובדה שהוצמד לה גג הבית המשותף, היא הפרשנות המתיישבת יותר עם ההיגיון.

32. בנוסף, העובדה שבעת רישום הבית המשותף, הדירות נרשמו בבעלות 2 החסויות בלבד, ולא היו בעלי דירות אחרים שיש להם אינטרס מנוגד לכך, אף היא מחזקת את המסקנה שכוונת מנסחי התקנון היתה להקנות לדירה 5 את מקסימום הזכויות שניתן להקנות לה, כדי לאפשר בהמשך מכירת הדירות האחרות תוך שמירת הפוטנציאל הכלכלי המקסימלי של אותה דירה עבור בעליה.

33. אני סבורה שגם רוכש דירה סביר, אשר קורא את ההוראה האמורה בתקנון, מבין שלדירה 5 בלבד יש זכויות בניה, ועולה שכך אף הבינו התובעים ומוכרי דירתם.

34. העובדה שמוכרי דירת התובעים לא דיווחו על זכויות בניה לצורך קבלת אישור העירייה, והעירייה ראתה בהם כמי שאינם מחוייבים בהיטל השבחה בשל היעדר זכויות בניה לדירתם, ושהתובעים עצמם לא דיווחו על זכויות כאמור לרשויות המס, מחזקת את המסקנה שהפרשנות האמורה היא הפרשנות הסבירה של הסעיף בתקנון, שכן הן התובעים והן מי שמכר להם את הדירה, פרשו כך את מצב זכויותיהם ובהתאם לכך הצהירו על היעדר זכויות כאמור. אמנם ככל שאכן היה נמצא שהתקנון מקנה להם זכויות בניה, היעדר הדיווח לא היה שולל מהם זכויות כאמור, אך לעובדה שסברו שאין להם זכויות כאמור במועד המשמעותי של רכישת הדירה, יש משקל לעניין האופן בו יש לפרש את התקנון.

35. מסקנת הדברים היא, שהפרשנות על פיה תקנון הבית המשותף מקנה לנתבעת את כל זכויות הבניה בבית המשותף, הן אלו שהיו לפני רישומו והן אלו שנוצרו לאחריו, היא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרשנות התואמת יותר את לשון התקנון והנסיבות המוסכמות על צדדים. מכל מקום, התובעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם, להוכיח שיש לפרש את התקנון באופן אחר על פי טענתם.

36. בשולי הדברים אוסיף שיש לסייג את האמור למצב חריג בו קיימת תכנית בניה המקנה זכויות בהיבטים **קנייניים** לדירה מסוימת, באופן מפורש וברור, שאז יתכן שיש לבחון את הדברים בצורה שונה (ר' ניתוח של אפשרות חריגה כאמור בת"א (שלום הרצליה) 4784/11/16 רז נ' **ארנן** (נבו 25.12.2018)). אולם בענייננו לא נטען שזכויות הבניה שנוספו לבית המשותף יועדו על פי התכנית באופן חריג לדירות מסוימות, ואף עולה שההיפך הוא הנכון, שכן הטענות הן לתוספת בניה על הגג, ועל כן אין צורך להכריע בשאלה תיאורטית זו.

האפשרות למימוש זכויות הבניה שבידי התובעת לאור הוראות התקנון

37. לאור ההכרעה בדבר זכותה של התובעת בכל זכויות הבניה, יש לבחון את השאלה, האם תוכל להשתמש ביתרת זכויות הבניה השייכות לה, לצורך בניה של יותר מקומה אחת, ומה דינו של הגג שיווצר לאחר בניה כאמור.

38. באשר להצמדת גג הבית המשותף, נקבע בפסיקה שניתן לרכוש כרכוש צמוד רק את מה שהוצמד מפורשות, ואם הוענקה זכות לבנות על השטח המוצמד, לא ניתן לראות את החלקים החיצוניים של מה שנבנה (קירות חיצוניים או גג) כמוצמדים לדירה, כל עוד לא נקבע כך מפורשות (בע"א 239/79 **ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם**, פ"ד לד(2) 807 (1980) (להלן – **עניין גלבורט**); ע"א 1121/91 משולם נ' נמני, פ"ד מח(3) 12, (1994) בעמ' 22, כן ר' **עניין קאופמן** פסקה 14).

39. יחד עם זאת, נאמר בעניין **גלבורט** בעמ' 811 (אם כי באמרת אגב):

"כאשר מבנה מוקם כדין כחטיבה אחת והדברים נמצאים בתהליך הבניה, עדיין איננו מתגבש הרכוש המשותף, אך כאשר הושלם המבנה הנוסף ונוצר על ידי כך גג חדש, הרי יש לבעלי הדירות מיניה וביה זכויות בו והוא כל עוד לא הסכימו בקשר לכך אחרת."

40. כך סבור גם המלומד ויסמן בספרו "**דיני קניין – בעלות ושיתוף**" (תשנ"ז) בעמ' 425:

"ברור כי אתנחתא קצרה בעבודות הבניה שבין קומה לקומה, לא תהפוך את תקרת הקומה העליונה ל"גג", שדינו כדין רכוש משותף, אם לא היתה לתקרת הקומה העליונה גימור האופייני לגגות. ואולם השיקול העיקרי שיש להתחשב בו נעוץ להערכתנו, לא כל כך במשך ההפסקה שחלה בעבודת הבניה, בין בניית הקומה העליונה ועד למועד שבו מבקשים להמשיך בבניה, ואף לא במצב הפיסי של הגג, אלא בכוונת הצדדים בעת שהוסכם על הצמדת הגג. הצמדת הגג לצרכי בניה נוספת היא זכות רבת ערך, אין לאפשר סיכול הכוונה האמיתית של הצדדים בעת שנרכשה הזכות הזאת על ידי טיעונים פורמליסטים בדבר הפיכתו של הגג לגג משותף, אף שטרם נסתיימו עבודות הבניה שניתנה להן הסכמה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. בענייננו, העובדה שכל הגג הקיים מוצמד לדירת הנתבעת, וכן נמצא שיש לה את כל זכויות הבניה, הרי שאין מקום לבצע אבחנה מלאכותית בין הקומות ולקבוע שהיא רשאית לבנות קומה אחת בלבד, בטענה שהגג שיוצר מעל אותה קומה הוא רכוש משותף. שילוב זכויותיה של הנתבעת מאפשר לה לנצל את מלוא זכויות הבניה שברשותה לצורך בניה על שטח הגג הצמוד לדירתה.

42. לפיכך, משנמצא שלנתבעת זכויות בניה המאפשרות בנייה של יותר מקומה אחת, אין מניעה שתבנה יותר מקומה אחת כל עוד הבנייה תעשה במסגרת אותן עבודות. זאת משום שעד להשלמת הבנייה הנוספת, לא מתגבש הרכוש המשותף.

43. להשלמת התמונה, אוסיף שכאשר תסתיים הבנייה, יהיה הגג החדש שייבנה רכוש משותף, כפי שאפרט להלן.

44. בעניין **מפעל חסד תורה** נסקרו ההיבטים הרלוונטיים לעניין:

"... השאלה למי הוקנו הזכויות הקנייניות בגג הבית המשותף או בחצר, אינה משליכה בהכרח על שאלת הקניית זכויות הבנייה באותו הגג או החצר (ענין ב"ב, בעמ' 501), ומדובר שתי שאלות נפרדות. ניתן על כן להגיע להסכמה חוזית לפיה זכויות בנייה קיימות או עתידיות בבית משותף יוקנו למי מבעלי הדירות באותו הבית, אף בלא הצמדת הגג או החצר שבהם ניתן לממש בנייה זו (ענין קאופמן, בפס' 9)."

מכאן, שהעובדה שהוקנו לדירת הנתבעת כל זכויות הבניה, אינה משליכה בהכרח על השאלה הקניינית של הצמדת הגג החדש.

45. בענייננו, שעה שלא נקבע בתקנון מפורשות שהגג החדש שייבנה יוצמד אף הוא לדירת הנתבעת, הרי שהגג החדש, ככל שייבנה, יהווה רכוש משותף השייך למבנה 1, לאור הוראת סעיף 2 לתקנון הקובעת שהרכוש המשותף של כל מבנה יוצמד למבנה שלו. על כן ככל שהנתבעת תרצה לבנות שוב על הגג החדש או להשתמש בו (כגון במצב שיאושרו בעתיד זכויות בניה נוספות), יהא עליה לקבל הסכמות מבעלי הדירות האחרים, ברוב הדרוש לפי העניין, בהתאם להוראות חוק המקרקעין, על אף שזכויות הבניה לבנייה נוספת כאמור, יהיו שייכות לה.

46. בהקשר זה אציין שאמנם תקנון הבית המשותף קבע שזכות בעלי דירה 5 לבקש תיקון צו הבית המשותף ולאשר שינוי תקנון ללא הסכמת יתר בעלי הדירות (סעיף 3(ב)), אך כל עוד לא נקבעה בתקנון הבית המשותף במפורש זכות להצמדה של רכוש משותף נוסף לדירה 5, לא יכולה הוראה זו לגבור על הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, הקובעת בנוגע לשינוי תקנון ש"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". דווקא העובדה שפורטו במקום אחר בתקנון אותם חלקים שיוצמדו לדירה 5, מחזקת את המסקנה שלא היתה כוונה להצמיד לדירה 5 חלקים נוספים מהרכוש המשותף.

ממיקומה של ההוראה האמורה בתקנון, הנמצאת באותו סעיף 3 המתייחס לעניין זכויות הבניה, נראה כי כוונתה היתה לאפשר לבעלי דירה 5 לתקן את צו הבית המשותף ולהתאימו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/106/2021, 1/179/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבניה שיבצעו על פי זכויות הבניה שהוקנו להם בסעיף 3(א) לתקנון, מבלי שיידרשו להסכמת יתר בעלי הדירות, אך לא היתה כוונה לתת להם זכות גורפת לבצע כל שינוי שהוא בתקנון, כולל כזה הפוגע בזכויות הקנייניות של בעלי דירות אחרים.

סיום

47. לאור האמור, אני קובעת כי הן זכויות הבניה שהיו קיימות בעת רישום הבית המשותף, והן אלו שנוספו לאחריו, שייכות לדירת הנתבעת. יחד עם זאת, הגג החדש שיווצר לאחר הבניה על הגג הצמוד על פי התקנון לדירת הנתבעת, יהווה רכוש משותף.

48. כדי למנוע מחלוקות נוספות בעניין זה בעתיד, אני מורה לרשמת המקרקעין בירושלים לרשום הערה על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, על חלקת הרכוש המשותף, על פיה "קיים פסק דין של המפקחת על רישום מקרקעין בירושלים בתיק 179/21 לעניין שיוך זכויות הבניה בבית המשותף לתת חלקה 5".

49. בנסיבות אלו, מכיוון שהתביעה נדחתה, ויחד עם זאת לאור ההסכמות הדיוניות של הצדדים שהביאו לקיצורו של ההליך, אני קובעת שעל התובעים לשלם לנתבעת הוצאותיה בסך של 6,000 ₪.

ניתן היום, 18 אוגוסט 2022, כ"א אב תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים